

1066936-49.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Marca

Magistrado: Eduardo Palma Pellegrinelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do "pacta sunt servanda" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit. - grifado).

Mais ainda, "As partes sabem que, estabelecido o vínculo do acordo, as vontades devem orientar-se segundo um princípio geral, mais forte e mais constante do que os mutáveis ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM

Praca Doutor Joao Mendes, S/N, São Paulo - SP - cep 01501-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1066936-49.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1066936-49.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Marca

Requerente:

Tsp Comercio Industria e Participacoes

Requerido:

Tartuferia Lorena Restaurante e Empório Ltda e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Palma Pellegrinelli

Vistos.

## 1. Relatório

Trata-se de ação promovida por TSP COMÉRCIO, INDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA contra TARTUFERIA LORENA RESTAURANTE E EMPÓRIO LTDA, FERNANDO SÉRGIO DE TOLEDO PORTO, MARIA AUGUSTA PINTO CORDEIRO MONTANHA TEIXEIRA e PM SINERGIA PARTICIPAÇÕES S/A visando compelir os réus a se absterem quanto à violação da marca "Tartuferia San Paolo" pertencente à parte autora, bem como quanto à comercialização de "seus pratos através de plataformas digitais para atendimento via delivery"; compelindo-os a se absterem também quanto ao uso dos elementos "que identificam o [seu] conjunto-imagem", a "retirar toda publicidade e informação veiculada na mídia impressa e/ou digital", e a "alterar o cardápio do restaurante, de modo a atender aos critérios previstos na cláusula 3.1.1 do Termo de Rescisão e Confissão de Dívida"; e, ademais, condena-los ao pagamento de valores devidos à parte autora a título de royalties e multa contratual (fls. 01/27).

Alega a autora, em síntese, que é titular da marca mista "'Tartuferia San Paolo'" e pactuou com a parte ré contrato de licenciamento para exploração da referida marca "no ramo de restaurantes"; que, em razão de inadimplementos da parte ré, as partes pactuaram termo de rescisão do negócio. Alega, ademais, que os réus deixaram de pagar valores devidos a título de royalties no período de fevereiro a abril de 2021, ensejando a cobrança do montante bem como a incidência de multa contratual; e que os réus deixaram de cumprir cláusula que estipulou proibições quanto ao uso "[d]a marca ou [d]a logomarca 'Tartuferia San Paolo, ou qualquer outra marca semelhante ou que remeta a um restaurante especializado em Trufas", à operação de "um restaurante especializado em trufas", bem como à divulgação ao público "como um restaurante especialista em trufas", e a exploração de cardápio com mais de 40% de pratos à base de trufas, por parte dos réus, até "o cumprimento integral de toda obrigação de pagar definida em contrato".

A petição inicial foi instruída com documentos (fls. 28/111).

O D. Juízo da 3ª Vara Cível do Foro Central Cível desta Capital reconheceu sua incompetência para processar e julgar a presente ação (fls. 112) e o processo foi redistribuído.

Foi determinado que os autores prestassem esclarecimentos (fls. 116), o que foi cumprido (fls. 119/128, instruída com documentos de fls. 129/142).

Considerando as peculiaridades do caso, foi facultado que a ré se manifestasse sobre a tutela de urgência (fls. 143/144).

Houve o comparecimento espontâneo dos réus, que, em sua manifestação sobre a tutela de urgência, alegaram, em síntese, que cumpriram os termos do distrato celebrado entre as partes, na medida em que criaram marca nova (fls. 153/169).

A manifestação foi instruída com documentos (fls. 170/190).

Foi concedida a tutela de urgência (fls. 196/200) para "determinar que os réus, no prazo de 05 dias contados da intimação desta decisão: (i) deixem de usar o termo "Tartuferia", de qualquer forma e por qualquer meio; (ii) deixem de se posicionar no mercado como um restaurante especialista em trufas; (iii) alterem o cardápio do restaurante, de modo a atender aos critérios previstos na cláusula 3.1.1 do Termo de Rescisão e Confissão de Dívida", sobrevivendo a r. decisão do E. Tribunal de Justiça que indeferiu a antecipação da tutela recursal (fls. 248).

Por ocasião da resposta (fls. 205/227), foi alegada, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos corréus PM SINERGIA, FERNANDO e MARIA AUGUSTA. No mérito, foi alegado, em síntese, que o uso da marca "Tartuferia Lagotto" não implicou violação à cláusula 3.1, alíneas 'a' e 'b' do termo de rescisão do contrato de licenciamento pactuado entre as partes; que a marca "Tartuferia Lagotto" foi concedida pelo INPI à parte ré, sem oposição da parte autora; que as obrigações financeiras assumidas na confissão de dívida "não puderam ser totalmente adimplidas até o momento em razão da dificuldade financeira que a Ré vem enfrentando diante dos efeitos decorrentes da pandemia do COVID-19"; que "não há qualquer semelhança entre as marcas da Autora e da Ré, seja com relação aos aspectos gráfico-visual ou fonético, que possa fundamentar a alegação da autora nesse sentido (...) a não ser pelo elemento nominativo descritivo 'Tartuferia'"; que "Tartuferia" é "elemento descritivo comum não (...) passível de apropriação exclusiva"; que "apesar da Ré trabalhar com trufas em seu menu (...), em nenhum momento a Ré se posiciona como especialista em trufas"; que "[o]s pratos essencialmente à base de trufas presentes no cardápio da ré (...) respeitam o limite de 40% ajustado no termo firmado entre as partes"; que os valores não pagos a título de royalties nos meses de fevereiro, março e abril de 2021 equivalem a R\$ 6.255,53, 5.992,44 e 5.915,14,

respectivamente; e que “o valor da multa pretendida pela autora diante do descumprimento dos royalties dos meses de fevereiro, março e abril de 2021, deve incidir tão somente sobre o montante total devido a esse título”.

A contestação foi instruída com documentos (fls. 228/244).

Houve réplica (fls. 252/268).

Sobreveio manifestação da parte autora alegando o descumprimento da tutela de urgência (fls. 269/277), instruída com documentos (fls. 278/315) e, após a determinação de fls. 316, houve manifestação da parte ré (fls. 319/327), instruída com documentos (fls. 328/337), sobrevindo o indeferimento da pretensão de fls. 269/277 (fls. 354/355).

As partes especificaram provas (fls. 360/363 e 364/367).

É o relatório. Passo a decidir.

## 2. Fundamentação

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte ré, eis que as obrigações de limitação à concorrência estipuladas no termo de rescisão do contrato de licenciamento pactuado entre as partes também foram impostas aos sócios da TARTUFERIA, tendo estes constado como testemunhas do instrumento (fls. 57/65).

Superada tal questão, está configurada a hipótese de julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), na medida em que a matéria de fato está satisfatoriamente provada por documentos, restando por isso indeferida a pretensão da parte ré pela produção de prova oral consistente no depoimento das partes e na oitiva de testemunhas (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Pois bem.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora é titular no INPI de registros de marcas mistas de produtos e serviços e de marca nominativa de serviços “Tartuferia San Paolo” (fls. 48/56) com especificações para serviços de restaurante e determinados produtos alimentícios (classes NCL(1): 43, 29 e 30, CFE (4): 3.1.8, 26.4.1, 27.5.1).

E de acordo com a Lei n. 9.279/96, sendo a marca o sinal distintivo visualmente perceptível que identifica o produto ou serviço (art. 122), cabe ao seu titular o uso exclusivo (art. 129) ou o licenciamento (art. 130, II), bem como, em qualquer das hipóteses, zelar pela sua integridade material e reputação – art. 130, III.

Nesse sentido, classifica-se como crime contra registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada (art. 189, inciso I), sendo que, tratando-se de marca sem alto renome, a colisão se dá a partir do momento em que a reprodução ou imitação se refere a produto ou serviço do mesmo ramo do mercado (princípio da especialidade). Além disso, comete crime de concorrência desleal quem “emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem” (art. 195, inciso III) – e a imitação de marca já explorada configura emprego de meio fraudulento.

Ademais, por força do art. 124, II, VI e XVIII, da Lei n. 9.279/96, não são registráveis como marca a “letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”, o “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma

característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva", assim como o "termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir".

Postas tais premissas, é incontroverso que as partes celebraram contrato de licença do uso da referida marca, que foi consensualmente rescindido.

Segundo o termo de rescisão de fls. 57/65, os réus reconheceram a existência de dívida e se comprometeram ao pagamento de determinado valor, podendo utilizar a marca "Tartuferia San Paolo" até o dia 30/04/2021.

As partes também disciplinaram a concorrência após a referida data, que foi limitada até o pagamento integral da dívida, assim tendo constado da cláusula 3.1, verbis:

3.1. Após a rescisão contratual a LICENCIADA poderá continuar atuando no mesmo endereço, tendo em vista ser titular do fundo de comércio estabelecido e titular no contrato de locação do estabelecimento, e poderá operar em qualquer ramo da gastronomia, desde que respeitadas as limitações ora determinadas, que perdurarão até o integral cumprimento da obrigação de pagar prevista na cláusula 1.2 deste instrumento, com exceção do item "a", cuja limitação decorre da Lei de Propriedade Industrial e perdurará enquanto a LICENCIANTE for a legítima detentora da marca em questão:

- a) A LICENCIADA, por meio de seus sócios e/ou representantes legais, não poderá utilizar a marca ou a logomarca "Tartuferia San Paolo", ou qualquer outra marca semelhante ou que remeta a um restaurante especializado em Trufas;
- b) A LICENCIADA, por meio de seus sócios e/ou representantes legais, não poderá operar um restaurante especializado em trufas, não poderá expor-se ao público como um restaurante especialista em trufas, de forma que não promova concorrência no ramo específico de atuação da LICENCIANTE.
- c) A LICENCIADA, por meio de seus sócios e/ou representantes legais, não poderá vender seja de forma presencial ou online, produtos e insumos a base de trufas, ou a própria trufa;
- d) A LICENCIADA, por meio de seus sócios e/ou representantes legais, não poderá promover ou participar de eventos que visem a divulgação de Trufas e/ou produtos Trufados

3.1.1 Não obstante as limitações temporárias acima estabelecidas, a LICENCIADA poderá conter em seu cardápio pratos à base de trufas ou que contenham este insumo dentre os seus ingredientes, desde que tais pratos não excedam o equivalente a 40% (...) da totalidade dos pratos que serão oferecidos ao público (fls. 61 - grifado).

E, nesse contexto, em que pese este magistrado decida reiteradamente pela impossibilidade da apropriação de termos comuns, o que, em princípio, possibilitaria a convivência entre as marcas "Tartuferia San Paolo" e "Tartuferia Lagotto", no caso a solução deve ser diversa.

É que os réus assumiram obrigações específicas no termo de rescisão, no sentido de: (i) não utilizar a marca "Tartuferia San Paolo" ou qualquer outra marca semelhante ou que remeta a um restaurante especializado em Trufas; (ii) não operar um restaurante especializado em trufas; (iii) não vender produtos e insumos a base de trufas não promover ou participar de eventos que visem a divulgação de trufas e/ou produtos trufados.

Além das obrigações aparentarem ser razoáveis, estão temporalmente limitadas, perdurando apenas "até o integral cumprimento da obrigação de pagar prevista na cláusula 1.2" do próprio termo de rescisão.

Portanto, para se eximir das restrições previstas na cláusula 3.1, em princípio bastaria que os réus tivessem cumprido a obrigação pecuniária prevista na cláusula 1.2.

E, como ensina Paula Forgioni, o funcionamento do mercado exige que os pactos sejam respeitados, de forma que "A força obrigatória dos contratos viabiliza a existência do mercado, coibindo o oportunismo indesejável das empresas" (in Contratos Empresariais. Teoria e Aplicação, 3ª ed., pp. 109/112, São Paulo, RT, 2018).

Ainda sobre o *pacta sunt servanda*, a Professora aponta que "Se lhes fosse permitido, os agentes econômicos valer-se-iam dos contratos para vincular apenas seus parceiros comerciais, e nunca a si próprios. No momento inicial, as partes creem que o negócio ser-lhes-á vantajoso; todavia, com o passar do tempo, é possível que o vínculo deixe de interessar a uma delas. Nasce anseio de se livrar da amarra contratual para seguir outro caminho. Partindo dessa premissa, compreende-se a importância sistêmica da força vinculante dos contratos; na sua ausência, seria impossível a coibição do descumprimento da palavra empenhada e o desestímulo de comportamentos oportunistas prejudiciais ao tráfico. O princípio do "*pacta sunt servanda*" mostra-se necessário ao giro mercantil na medida em que freia o natural oportunismo dos agentes econômicos" (op. cit. - grifado).

Mais ainda, "As partes sabem que, estabelecido o vínculo do acordo, as vontades devem orientar-se segundo um princípio geral, mais forte e mais constante do que os mutáveis interesses individuais. Nesse esquema, a liberdade [autonomia privada] é sacrificada em prol da segurança, da previsibilidade [ou da "segurança externa"]". (...) Ao contratar, uma parte tem a legítima expectativa de que a outra comportar-se-á de determinada forma, daquela maneira anônima e repetida a que fizemos referência. Ambos os empresários planejam sua jogada e esperam que o outro "aja" de acordo com esse padrão "de mercado". Não é desejável que seja dada ao contrato interpretação diversa daquela que pressupõe o comportamento normalmente adotado [usos e costumes]. Isso levaria ao sacrifício da segurança e da previsibilidade jurídicas" (op. cit., pp. 119/120 - grifado).

Ainda nesse sentido, é importante observar que "Por conta da adoção do padrão de comportamento do homem ativo e probo, ou dos "comerciantes cordatos", o ordenamento jurídico autoriza a pressuposição de que o agente econômico, de forma prudente e sensata, avaliou os riscos da operação e, lançando mão de sua liberdade econômica, vinculou-se. O sistema supõe que, naquele momento, o mercador entendeu que o contrato ser-lhe-ia vantajoso; essa expectativa pode até restar frustrada - e aí reside o "risco do negócio" (op. cit., pp. 120/122 - grifado).

Portanto, deve ser presumido que as partes, devidamente assessoradas, compreenderam (ou deveriam ter compreendido) a amplitude das obrigações assumidas por meio do instrumento de fls. 57/65, razão pela qual seus termos não podem ser relativizados, o que significa reafirmar a importância da autonomia privada.

E, nesse contexto, é de rigor a condenação dos réus a se absterem quanto ao exercício de atividade "no ramo da gastronomia, mediante o uso e exploração de qualquer marca semelhante àquela pertencente à Autora", bem como ao posicionamento "como um restaurante especialista em trufas" e à exploração de cardápio com mais de 40% dos pratos com trufas, até que quitados os débitos indicados no item 1.2 do termo de rescisão do contrato (fls. 58).

Outrossim, restou incontroverso o inadimplemento dos valores devidos pela parte ré a título de royalties nos meses de fevereiro, março e abril de 2021, nos valores de R\$ 6.255,53, 5.992,44 e 5.915,14, respectivamente, ressaltando-se que a parte autora não impugnou especificamente tais favores.

Destarte, é de rigor a condenação da parte ré ao pagamento dos valores de R\$

6.255,53, 5.992,44 e 5.915,14, respectivamente, a título de royalties devidos pelo licenciamento da marca nos meses de fevereiro, março e abril de 2021, com correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde a data do vencimento das referidas taxas, e juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação.

Por fim, observa-se que a existência de multa semelhante aplicável na hipótese de inadimplemento dos valores que foram objeto de confissão de dívida não obsta a exigibilidade da multa prevista da cláusula 6.1 do termo de rescisão, tendo em vista que reconhecido o inadimplemento da obrigação pertinente à limitação da concorrência, sendo, portanto, de rigor a condenação da parte ré ao pagamento da multa no valor de R\$ 52.505,00

### 3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo o pedido procedente para:

determinar a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do CPC;  
condenar os réus a se absterem quanto ao exercício de atividade “no ramo da gastronomia, mediante o uso e exploração de qualquer marca semelhante àquela pertencente à Autora”, bem como ao posicionamento “como um restaurante especialista em trufas” e à exploração de cardápio com mais de 40% dos pratos com trufas, até que quitados os débitos indicados no item 1.2 do termo de rescisão do contrato (fls. 58);  
condenar os réus ao pagamento dos valores de R\$ 6.255,53, 5.992,44 e 5.915,14, respectivamente, a título de royalties devidos pelo licenciamento da marca nos meses de fevereiro, março e abril de 2021, com correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde a data do vencimento das referidas taxas, e juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação;  
condenar a parte ré ao pagamento da multa no valor de R\$ 52.505,00, em razão do inadimplemento da obrigação de não-concorrência;  
determinar que a apuração dos valores devidos nos termos dos itens 'c' e 'd' depende de mero cálculo aritmético (art. 509, § 2º, do CPC), que deverá ser elaborado diretamente pelo credor;  
com fundamento no – art. 85, § 2º, do CPC, condenar os réus ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor do advogado contratado pelos autores, fixados em 10% do valor da condenação. Observo que em relação às custas e às despesas processuais, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir de cada adiantamento, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da condenação. Em relação aos honorários advocatícios, haverá a incidência de correção monetária pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da data da propositura da ação, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA